

1515349-95.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515349-95.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515349-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181429/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 25954450 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2181429 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MIGUEL MARTINEZ CARDOSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

GUSTAVO MIGUEL MARTINEZ CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, no dia 05 de julho de 2022, por volta das 17h15, na Rua Cosme Damião da Cunha, nº 214, Viela 77, Jardim Guarani, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o acusado, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 50 porções de maconha (peso líquido de 402g), 102 porções de cocaína e 33 porções de cocaína na forma de crack (peso líquido de 45,4g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado. Ao perceber a presença dos policiais, GUSTAVO

correu, ensejando perseguição policial. Durante a fuga, o denunciado caiu de um declive e veio a se lesionar, ao que foi alcançado pelos policiais.

Com GUSTAVO foi encontrada, em sua cintura, uma sacola plástica contendo diversos entorpecentes, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 08/09, e R\$ 201,00 (duzentos e um reais) em dinheiro. Indagado, confessou a prática delitiva, assumindo a propriedade dos entorpecentes e afirmando que "a casa havia caído" [sic]. Interrogado, GUSTAVO ficou em silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida e agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de novembro de 2022 (fls. 84/87). O acusado foi citado (fls. 104), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 68/69).

Durante a instrução de causa foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado. Contudo, diante das condições favoráveis do réu, não se opôs a concessão do redutor e ao regime aberto.

A Defesa acompanhou.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/07); o auto de prisão em flagrante (fls. 04); o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); o laudo pericial (fls. 14/17; 75/77).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e dos laudos de constatação provisória (fls. 14/17), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 75/77), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Em juízo dois policiais foram ouvidos e ambos além de reconhecerem o acusado confirmaram os fatos narrados na denúncia, vejamos.

O policial Michel reconheceu o acusado. Em uma operação Sufoco, e tiveram denúncia de que nessa região havia tráfico de drogas e então fizeram uma incursão na comunidade. Se depararam com o acusado que vinha correndo em direção a equipe do declarante. Não sabe se ele estava correndo de outros policiais. Ele veio de frente e então pediu para que ele parasse. Ele obedeceu a ordem de parada e dentro de sua calça localizou uma sacola preta. Dentro da sacola localizou diversos tipos de entorpecente, com certeza cocaína e maconha. Outros entorpecentes também estavam na sacola mas não se lembra qual. A quantidade era para comercialização, tudo já fracionado para venda. Em torno de 70 unidades de um tipo, 60 unidades de outro. Ele confessou. Disse que estava correndo porque estava fugindo de outros policiais. Ele admitiu que estava comercializando a droga. Não o conhecia antes. Era de dia. Não houve qualquer intercorrência na nossa abordagem. Pelo que se recorda, um parente dele apareceu para trazer os documentos, não se recorda quem. Segundo foi informado, ele residia a um quilometro do local em que foi preso.

O policial Eduardo também recordou-se do réu. Estavam desencadeando uma operação pela área do batalhão e ingressaram, junto com outros policiais e viaturas ingressaram na Rua Cosme Damião da Cunha. Se depararam com o acusado correndo. Ele disse que estava correndo porque viu muitos viaturas entrando na comunidade. Na cintura dele encontrou uma sacola plástica preta com entorpecente, maconha crack e cocaína, já divididos e embalado para venda. Tinha mais de 70 porções de droga no total. Não pode precisar quanto. Está há 27 anos na polícia e realiza uns 10 flagrantes por mês, só de tráfico de drogas. Está há 27 anos na polícia. Com tudo, acredita que faz uns 25 flagrantes por mês. Ele admitiu o tráfico, estava com filho

pequeno e que estava trabalhando com isso há um tempo.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

Gustavo tem 21 anos de idade. É solteiro e tem uma filha de 05 anos. Ela fica 15 dias com a mãe e 15 dias com o interrogando. Fazia entrega de bicicleta para o Ifood. Mora com a genitora. Tem uma receptação mas não foi condenado. Reconhece os fatos. Estava desempregado e ficou desesperado. Passou a receber 300 reais por três dias de trabalho. Estava no segundo dia de tráfico e já foi preso. Reconhece que estava com o entorpecente mencionado na denúncia. Está arrependido.

Como se percebe da prova colhida, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena além do mínimo legal.

Em terceira fase, nos termos das bem lançadas ponderações trazidas pelo Ministério Público, com as quais concordou a Defesa, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.61. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a

máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno GUSTAVO MIGUEL MARTINEZ CARDOSO, RG: 56319264, CPF: 544.478.758-02, nascido em 21/04/2001, natural de São Paulo - SP, filho de Helio Santos Cardoso e Arlei Martinez, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição

ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 11). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06;

Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA